

1500143-82.2021.8.26.0646

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Marcela Corrêa Dias de Souza

Comarca: Urânia

Foro: Foro de Urânia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... de um indivíduo preso em flagrante por tráfico de drogas. Mencionou que Andrei relatou que eles trocaram as bicicletas por pedras de "crack", com um adolescente conhecido por "Luizinho", que também foi apreendido por ato infracional equivalente ao tráfico de drogas.

A testemunha Marcos Rogério Taqueto, policial militar, ouvida apenas em juízo, disse que conhece os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Urânia

Foro de Urânia

Vara Única

Avenida Barão do Rio Branco, 818, Urania - SP - cep 15760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500143-82.2021.8.26.0646 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500143-82.2021.8.26.0646

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDREI LUCIANO ROQUE e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcela Corrêa Dias de Souza

Vistos.

ANDREI LUCIANO ROQUE e AMAURY VENTURA BARRETO, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, incisos II e IV, do Código Penal, por 02 (duas) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (crime continuado), pela prática dos fatos delituosos assim narrados na denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que ANDREI LUCIANO ROQUE (vulgo "Ratinho") e AMAURY VENTURA BARRETO (vulgo "Pernambuco"), qualificados nos autos, nos locais e datas abaixo relacionados, durante o repouso noturno, agindo em concurso, mediante escalada e em continuidade, nas mesmas condições de tempo, local e maneira de execução, subtraíram para eles 03 (três) bicicletas, pertencentes às vítimas Carlos José Della Libera e Luís Cardoso dos Santos.

Em data de 21 de dezembro de 2020, por volta de 03:30 horas, os denunciados ANDREI e AMAURY pularam o muro da frente da residência de Luís Cardoso dos Santos, localizada na Rua Ceará, nº 259, Nossa Senhora de Fátima, na cidade e Comarca de Urânia, de onde subtraíram 01 (um) bicicleta.

E, em data de 25 de dezembro de 2020, durante a madrugada, os denunciados ANDREI e AMAURY ingressaram na residência localizada na Rua Pará, nº 1298, Nossa Senhora de Fátima, na cidade e Comarca de Urânia, após pularem o muro localizado na área externa da vanguarda do imóvel, de onde furtaram 02 (duas) bicicletas.

Os bens furtados foram utilizados para a aquisição de drogas".

A denúncia foi oferecida em 10 de agosto de 2021 (fls. 132/135) e recebida em 12 de agosto de 2021. Na oportunidade, foi determinado o arquivamento dos autos do inquérito policial em relação a eventual crime de furto perpetrado em face da vítima R.R.S.S. (fls. 136/138)

Os acusados foram citados pessoalmente (fls. 188/189) e apresentaram resposta à acusação (fls. 195/198).

Houve a ratificação do recebimento da denúncia, oportunidade em que foi designada audiência de Instrução (fls. 204/208).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas pela acusação, bem como os acusados foram interrogados (fls. 244/245).

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, o Ministério Público requereu a vinda de laudo pericial do local dos fatos e auto de avaliação, o que foi deferido (fls. 244/246).

Foi deferido o pedido de justiça gratuita aos réus (fls. 255).

O auto de avaliação e o laudo pericial foram juntados aos autos (fls. 258/265).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos moldes preconizados na denúncia. Sustentou que as provas são firmes e suficientes a embasar o decreto condenatório. Pugnou pela procedência do pedido de condenação (fls. 269/277).

A defesa, por sua vez, alegou que não há provas suficientes para a condenação. Narrou que não há testemunhas presenciais dos fatos. Disse que o acusado Amaury negou a prática dos furtos. Requereu a improcedência da ação penal e a absolvição dos acusados (fls. 281/283).

É, em síntese, o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública promovida pelo Ministério Público visando a condenação dos acusados Andrei Luciano Roque e Amaury Ventura Barreto nas sanções do crime previsto no artigo 155, §§1º e 4º, incisos II e IV, do Código Penal, por 02 (duas) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (crime continuado).

A pretensão punitiva deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito está perfeitamente demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 03/04 e 06/07), laudo pericial do local dos fatos (fls. 12/18 e fls. 261/265), relatórios de investigações (fls. 23/26 e fls. 28/31), bem como pelas demais provas produzidas no decorrer da instrução.

A autoria também é incontroversa.

O acusado Amaury Ventura Barreto, na fase de inquérito policial, a fls. 19, disse: "Após tomar ciência do RDO 429/2020 Del Pol Urânia/SP, declarou que atualmente estou trabalhando na Usina Arakaki em Fernandópolis, passando veneno na lavoura e estou recebendo o valor de R\$ 1.600,00 ao mês, trabalho neste emprego há 3 meses. Que desconheço esses fatos narrados pelo ANDREI LUCIANO ROQUE, vulgo ratinho, que eu sou realmente usuário de droga, porém não furto nada de ninguém, eu já trabalho para manter minhas coisas".

Em juízo, disse que não participou dos furtos. Afirmou que já usou de drogas junto com Andrei. Relatou que foi abordado por policiais militares em companhia de Andrei, oportunidade em que disseram que comprariam cigarro no "Posto Paulistão". Mencionou que os comentários na cidade foram de que Andrei praticou furtos de bicicletas em dezembro de 2020. Disse que está internado em uma clínica de recuperação em São José do Rio Preto-SP, em razão da dependência de drogas. Salientou ser usuário de "crack". Afirmou que, no final de 2020, fez uso de droga com "Ratinho". Não sabe dizer como ele adquiriu as drogas que usaram. Contou que não teve nenhum desentendimento com Andrei. As drogas que usaram eram de "Ratinho". Disse que tem o apelido de "Pernambuco".

O acusado Andrei Luciano Roque, na fase extrajudicial, a fls. 20/21, disse: "Em relação ao Boletim de Ocorrência número 427/2020, informo que na data do dia 24 para o dia 25.12.2020, por volta das 02h da manhã, eu e Amaury, conhecido como Pernambuco ou Risadinha furtamos duas bicicletas, na Rua Pará, nº 1298, Bairro Nossa Senhora de Fátima, neste. Que eu escalei o muro da frente da residência e encontrei as duas bicicletas, as quais estavam presas na parede da garagem, lado de dentro, por ganchos. Que passei referidas bicicletas sobre o muro para meu colega Amaury, conhecido como Pernambuco ou Risadinha, e fomos direto para a casa de Luizinho, filho de Carla, o qual reside com sua avó, perto do cemitério, e, em troca, como forma de pagamento Luizinho os deu 40 pedras de craque. Cada pedra está custando hoje o valor de R\$ 10,00, totalizando R\$ 400,00 em pedras pelas duas bicicletas, cada bicicleta foi passada pelo valor de R\$200,00. Uma bicicleta era de cor branca e a outra bicicleta de cor preta e branca, sendo as duas com marcha, não me recordo a marca e nem modelo. Sabia que naquela casa existia as bicicletas pois 4 dias antes passei e vi elas na garagem, então resolvi furta-las, no dia dos fatos percebi que o carro da vítima, uma pickup, não estava na garagem e deduzi que a casa estava vazia e então em companhia do meu amigo Risadinha praticamos o furto. Em relação ao Boletim de Ocorrência número 429/2020, alguns dias antes desse furto acima que confessei, mais precisamente na madrugada do domingo para segunda (dia 20/12/2020 para o dia 21/12/2020), por volta das 03:30h da madrugada eu e Amaury conhecido como Pernambuco ou Risadinha furtamos outra bicicleta na rua Ceará, da mesma forma, eu adentrei na casa, pulando o muro da frente, peguei a bicicleta a qual estava no quintal, próximo a porta da sala e passei pelo muro para Amaury, e levamos novamente diretamente para "Luizinho", que nos deu em troca da bicicleta 20 pedras de craque. Era uma bicicleta de cor preta com marcha, também não me recordo a marca e modelo, quando pratico furto não reparo nesses detalhes. Eu e Risadinha fomos fumar as pedras de craque. Tenho conhecimento que Luizinho acompanhado de Flávio, genro de Roge cigano, levaram as bicicletas para uma cidade vizinha, acredito que levaram tais bicicletas para cidade de Fernandópolis/SP para vender. Acredito que Luizinho e Flávio já tem pessoas certas que comprem estas bicicletas que furtamos. A pessoa de Amaury, conhecido como Risadinha ou Pernambuco, reside na cidade de Urânia, no bairro Nossa Senhora de Fátima, não sei o local exato em que ele reside, sempre trombo com ele na Cohabinha (Bairro Vicente Filié) é indivíduo que aparente ter uns 30 anos, branco, de estatura pequena, magro, cabelo curto, não me recordo se tem tatuagem".

Em juízo, disse que já respondeu a outros processos criminais pela prática de furtos, bem como já foi preso. Disse que confirma a prática dos fatos descritos na

denúncia. Realmente furtou as bicicletas. Afirmou que entrou na residência da vítima Carlos pelo muro. Contou que alguns dias antes havia visto as bicicletas. Mencionou que procurou residências que tinham menos vigilância. Confirmou que trocou as três bicicletas por drogas. Narrou que foi ele quem pulou na casa de Carlos e passou as bicicletas para o acusado Amaury. Afirmou que essa forma de execução também foi realizada na outra residência. Disse que, quando foram abordados pelos policiais militares, pretendiam comprar cigarro no "Posto Paulistão", mas afirmaram que "estavam indo para furtar mesmo". Narrou que era comum praticar os furtos durante a madrugada. Disse que o acusado Amaury também usou "crack" com ele.

A vítima Carlos José Della Libera, na fase extrajudicial, a fls. 05 disse que: "Era véspera de natal do ano passado, fui para a casa de minha mãe na cidade de Estrela D'Oeste, em minha casa ficou minha esposa e meu filho. Acredito que naquela madrugada do dia 24 para 25 de dezembro, indivíduos pularam o muro da frente da minha casa, pois havia marcas de escalada, minha esposa e meu filho nada perceberam. Quando voltei para casa no dia 25 por volta das 08h30min, ao abrir o portão eletrônico, já senti a falta de 2 bicicletas minhas, elas ficavam penduradas em suporte na garagem. Acionei a polícia e posteriormente registrei a ocorrência. Quero registrar que no dia 24, quando sai de casa por volta das 16h30min, observei que na esquina da minha casa, havia dois indivíduos que os conheço pelos apelidos de "Ratinho e Pernambuco", ambos estavam ao meu ver em atitude suspeita, eles estavam observando as casas do bairro. Em meados do mês de fevereiro, fui comunicado, que a polícia de Jales tinha localizado uma das minhas bicicletas, ao qual me foi restituída por esta delegacia pelo policial MARCOS."

Em juízo, declarou que, no dia 24 de dezembro de 2020, foi até a cidade de Estrela D'Oeste, para ficar com sua mãe, que tem problemas de saúde. Narrou que saiu por volta de 16:30 horas. Quando saiu, viu que dois indivíduos estavam na esquina de sua casa. Conhecia "Ratinho" de vista, mas não conhecia Amaury. Confirmou que "Ratinho" tem a fama de "roubar os outros". Narrou que voltou para Urânia no dia seguinte e, ao chegar em sua residência, constatou o furto das bicicletas. Disse que as bicicletas ficavam penduradas no muro de sua casa. Contou que acredita que os indivíduos escalaram o muro de sua residência para a prática da subtração. Narrou que apenas uma das bicicletas foi recuperada.

A vítima Luiz Carlos Cardoso dos Santos, em solo policial, a fls. 08, narrou que: "Não me recordo exatamente a data dos fatos, só lembro que era no final de dezembro passado, estava no turno da noite em meu serviço, portanto, cheguei em casa por volta das 08h30min, minha esposa já tinha saído para trabalhar na padaria, ela sai de casa por volta das 05h30min. Assim que entrei em casa, senti falta de minha bicicleta, ela ficava no fundo da garagem, entre o carro e parede. Chamei um amigo, fizemos umas rondas, porém sem sucesso. Até o momento não tive informações da minha bicicleta, por ela paguei na época cerca de R\$ 1.000,00".

Em juízo, disse que, na época dos fatos, trabalhava no período noturno e, ao sair de casa, a bicicleta estava em sua residência. Afirmou que, ao retornar, constatou o furto da bicicleta. Declarou que a bicicleta estava na garagem de sua residência. Acredita que o acesso foi pulando o muro ou quebrando o cadeado do portão. Disse que o cadeado não estava danificado e, assim, acredita que eles pularam o muro. Afirmou que a bicicleta não foi recuperada.

A testemunha Marco Aurélio Bonello, investigador de polícia, ouvida apenas em juízo, disse que conhece os acusados dos meios policiais pela prática de furtos e uso de drogas. Alegou que participou das investigações relativas aos dois furtos. Afirmou que, na última semana de 2020, foram registrados vários furtos de bicicletas e, de início, em troca de informações com policiais militares, foi verificado que os acusados foram surpreendidos na noite do dia 24 de dezembro de 2020, perambulando pela cidade, tendo eles dito que comprariam cigarro em um posto

de gasolina próximo à rodovia. Disse que fez contato com a vítima Carlos, que disse suspeitar de dois rapazes, quais sejam, "Ratinho" e "Pernambuco". Narrou que indagou o acusado Andrei, que confessou o furto das duas bicicletas na Rua Pará, da vítima Carlos, bem como de uma bicicleta localizada na Rua Ceará, da vítima Luis. Mencionou que "Ratinho" disse que pularam o muro e retiraram as bicicletas que estavam em suportes de ferro. Afirmou que "Ratinho" admitiu a coautoria de Amaury. Com relação à abordagem sofrida com Amaury, "Ratinho" disse que eles estavam procurando uma residência fácil de furtar. Esclareceu que ambos os furtos foram praticados mediante escalada, segundo a versão de Andrei. Asseverou que, com relação à bicicleta de Luis, segundo Andrei, estaria na garagem. Disse que apenas uma bicicleta foi recuperada em Jales, na residência de um indivíduo preso em flagrante por tráfico de drogas. Mencionou que Andrei relatou que eles trocaram as bicicletas por pedras de "crack", com um adolescente conhecido por "Luizinho", que também foi apreendido por ato infracional equivalente ao tráfico de drogas.

A testemunha Marcos Rogério Taqueto, policial militar, ouvida apenas em juízo, disse que conhece os acusados dos meios policiais pela prática de furtos e uso de droga. Relatou que, no dia 24 de dezembro de 2020, abordaram os acusados na rua, os quais disseram que iriam até o "Posto Paulistão" para comprar cigarro. Mencionou que, no dia seguinte, tiveram a notícia da ocorrência de furtos. Mencionou que o "Posto Paulistão" ficava na direção contrária das residências dos acusados.

Eis as provas colhidas.

O delito de furto, na modalidade simples ou qualificada, exige o dolo do agente, consubstanciado na vontade consciente de apoderar-se definitivamente, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel, assim considerada como aquela que não pertence ao agente que pratica a subtração.

Adotada a teoria da amotio, a consumação do crime de furto ocorre no momento em que, cessada a clandestinidade por parte do agente, há inversão da posse em favor do agente, sendo desnecessárias a posse mansa e pacífica e a retirada da esfera de vigilância da vítima.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.524.450, sob a relatoria do Min. Nefi Cordeiro, em sede de recurso repetitivo (TEMA 934), fixando a seguinte tese: "consume-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"

No mais, entende-se cessada a clandestinidade quando o agente consegue deslocar o bem do local onde se encontrava, ainda que seja ele imediatamente perseguido e preso.

No caso sub judice, as provas amealhadas nos autos trazem tranquilidade necessária ao édito condenatório dos acusados como incurso nas sanções do crime de furto.

Com efeito, ambas as vítimas confirmaram que foram subtraídas de suas residências as bicicletas descritas na denúncia. Relataram que, para tanto, possivelmente os indivíduos utilizaram-se de escalada, pulando o muro.

O investigador de polícia Marco Aurélio Bonello, por seu turno, relatou que, durante a investigação dos furtos, o acusado Andrei admitiu ser o autor dos furtos das bicicletas narrados na denúncia. Mencionou que o acusado Andrei relatou ter praticado o furto em concurso com o acusado Amaury e mediante escalada, pulando o muro da residência.

Saliente-se que os depoimentos dos policiais são merecedores de confiança, como de resto qualquer outro depoimento, até que se prove o contrário. E, no contexto

probatório apresentado nos autos, nada há para lhe retirar o crédito de que seja merecedor.

HUGO NIGRO MAZZILLI, de forma lapidar, assim se expressou sobre o testemunho de policiais:

Não merece o depoimento dos policiais uma eiva abstrata e genérica de suspeição. Se o Estado encarrega seus agentes do grave munus de defender a coletividade contra o crime, se os arma, se lhes dá poder de polícia, se lhes atribui a investigação de crimes e até o direito de prender pessoas e apreender bens, seria rematado contra-senso recusar-lhes a priori qualquer crédito ao seu depoimento, apenas porque são policiais. Ora, seu testemunho há de ser aferido no contexto instrutório, no seu todo, e se, longe de desmentido pela instrução, for com esta coerente, razão não há para recusá-lo (RT, 417:94). Ou mais, seria indesculpável dislate obrigar os policiais a combaterem o crime e, depois, negar validade a seu subsequente depoimento. (in QUESTÕES CRIMINAIS CONTROVERTIDAS, Saraiva, 1999, pág. 776).

Nesse sentido, também se posiciona a jurisprudência pátria:

Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição. (RT.614/2756). No mesmo sentido, TJMG: RT. 444/406, 604/407; TJRJ: RT.595/423 etc.

Apelação do Ministério Público - Réus denunciados por furto duplamente qualificado tentado e corrupção ativa, em concurso material - Absolvição na instância anterior - Autoria e materialidade bem comprovadas, entanto - Palavras coerentes e uniformes da vítima - Depoimentos dos agentes policiais harmônicos desde a fase inquisitiva - Condenações de rigor - Prescrição em concreto da pretensão punitiva que se reconhece de ofício, todavia - Inteligência do art. 107, IV, c/c os arts. 109, V e 119 do CP - Recurso ministerial provido, reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade. (TJSP; Apelação 0019026-50.2011.8.26.0405; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 12ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Osasco - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/08/2017; Data de Registro: 01/09/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA - CONDENAÇÃO IMPOSTA - RECURSO DEFENSIVO EM BUSCA DA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - OS POLICIAIS CONFIRMARAM OS FATOS COM RELATOS COERENTES ENTRE SI - NEGATIVA ISOLADA DO RÉU - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENAS APLICADAS NOS MÍNIMOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação 0005382-56.2011.8.26.0238; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ibiúna - 2ª Vara; Data do Julgamento: 15/08/2017; Data de Registro: 17/08/2017)"

Não bastasse, em nenhum momento, seja na fase policial ou em juízo, os acusados trouxeram aos autos quaisquer elementos probatórios que pudessem ser utilizados para desmerecer o relato prestado ou que pudessem indicar que os policiais tinham motivos para imputar falsamente aos acusados crime que não cometeram.

A versão do investigador de polícia é corroborada pelo próprio acusado Andrei Luciano Roque, que, em solo policial e em juízo, confessou a prática delitiva e afirmou que o acusado Amaury participou dos dois furtos. Narrou que ele pulou o muro e passou as bicicletas para Amaury, que aguardava do lado de fora. Disse que, posteriormente, trocaram as bicicletas por drogas.

E, como se sabe, a confissão judicial tem grande valor, não podendo ser recusada, especialmente quando é sincera e não contrária ao contexto probatório amalhado. Já

decidiu o Supremo Tribunal Federal que “as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais” (RTJ 88/371).

Em que pese o acusado Amaury Ventura Barreto tenha negado a prática dos furtos das bicicletas descritas na denúncia, certo é a versão do acusado Andrei é verossímil, dando detalhes da prática delitiva.

Registre-se, ainda, que o policial militar Marcos Rogério Taqueto relatou que encontrou com ambos os acusados na via pública no dia anterior de um dos furtos (24/12/2020), indicando que eles eram amigos e atuavam juntos na prática de furtos.

Caracterizada, portanto, a responsabilidade penal de ambos os acusados pelos dois crimes de furtos descritos na denúncia.

Também não há dúvida acerca da configuração das qualificadoras, previstas no parágrafo 4º, incisos II e IV, do artigo 155 do Código Penal.

O concurso de agentes está devidamente comprovado, já que ambos os réus praticaram o delito na companhia um do outro, em unidade de desígnios.

Igualmente, a qualificadora prevista no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, do Código Penal, também está presente em ambos os furtos, uma vez que os acusados valeram-se de escalada para subtração da res furtiva.

A escalada, segundo ensina Cléber Masson,

"é a utilização de uma via anormal para entrar ou sair de um recinto fechado em que o furto será ou foi praticado. Contrariamente ao que sugere seu nome, é prescindível à imputação da qualificadora a ultrapassagem de um muro ou obstáculo pelo alto. Basta o ingresso ou retirada de forma anormal, extraordinária, a exemplo do que se dá na escavação de um túnel, em recinto fechado, pois se o local é aberto não há necessidade de escalada O meio anormal (fora dos padrões do homem médio) pode concretizar-se pelo uso de instrumentos (exemplos: cordas, escadas, tábuas, tijolos empilhados etc.) existentes no local do crime ou para lá levados propositalmente, ou mesmo pela peculiar habilidade física do agente (exemplo: sujeito que transpõe um muro valendo-se das saliências nele existentes). (...) Além disso, o obstáculo deve ser contínuo, não oferecendo alternativas à execução do crime sem o recurso à escalada. Se, exemplificativamente, o muro contém buracos pelos quais pode passar uma pessoa, ou se não cerca todo o prédio em que o furto é cometido, não incide a qualificadora. Quando a escalada envolve um muro ou parede a ser ultrapassado por cima, não há limite predeterminado para caracterização da qualificadora. O que se deve ter em mente é o meio anormal para entrada ou saída do palco do crime.

No caso em questão, o acusado utilizou-se de esforço anormal para que pulasse o muro e fosse possível a subtração do bem pertencente à vítima.

Com efeito, o perito criminal apontou que, em relação ao furto ocorrido na Rua Pará, o muro possui 2,40 metros de altura, além de possuir marcas que são compatíveis com a escalada (fls. 12/18).

Por sua vez, no tocante ao furto ocorrido na Rua Ceará, constatou-se que o muro possui 2,10 metros de altura, conforme laudo pericial (fls. 261/265).

Anote-se que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela presença da escalada quando o agente salta muro de 1,80 metro de altura:

CRIMINAL. RESP. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DA ESCALADA. TRANSPOSIÇÃO DE MURO

DE 1,80 M. CARACTERIZAÇÃO. MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. APLICAÇÃO AO FURTO QUALIFICADO PELA MESMA CIRCUNSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A escalada pressupõe a entrada em um local por um meio anormal, exigindo do agente esforço físico incomum, como saltar um muro de 1,80 m de altura, conforme ocorrido in casu. II - A qualificadora da escalada incide contra aquele que não se intimida diante de um obstáculo, demonstrando uma tendência maior do agente em delinquir. III - Viola o princípio da legalidade a aplicação da majorante do crime de roubo, resultante do concurso de pessoas, ao crime de furto qualificado pela mesma circunstância. IV - Tendo o Tribunal a quo, apesar de reconhecer a presença da circunstância qualificadora do crime de furto, recorrido aos princípios da proporcionalidade e da isonomia para aplicar dispositivo legal estranho ao fato, assume papel reservado pela Constituição Federal ao parlamento. V - Como não existe paralelismo entre os incisos I, II e III do § 4º do art. 155 do Código Penal com os demais incisos do § 2º do art. 157 do Estatuto Repressivo, a fórmula aplicada resultaria numa reprimenda diferenciada para indivíduos que cometem furto qualificado naquelas circunstâncias, o que é inconcebível. VI. Recurso Especial conhecido e provido, nos termos do voto do Relator. (STJ - Resp: 680743, RS 2004/0122763-8, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 02/12/2004, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação 09/02/2005)

No mesmo sentido, são os julgados do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação - Furto qualificado - Absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Prova segura corroborada pela confissão judicial do réu, depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão do réu na posse dos objetos subtraídos - Residência guardada por muro de 1,80 metros - Qualificadora da escalada configurada - Réu portador de maus antecedentes e reincidência em crimes da mesma natureza - Penas e regime prisional ajustados ao caso concreto - Recurso desprovido (TJ-SP, Apelação nº 0001009-43.2017.8.26.0279, Relator: Osni Pereira, Data de Julgamento: 30/01/2018, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/01/2018)

Apelação criminal - Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada, na modalidade tentada - Sentença condenatória pelo art. 155, § 4º, inciso I e II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal - Recurso Defensivo buscando, preliminarmente, a nulidade da r. sentença em razão da ausência de avaliação dos objetos furtados. No mérito, busca a absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de furto simples, com o benefício previsto no parágrafo 2º do referido artigo, a diminuição da pena, e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos - Preliminar - Rejeitada - Ausência de laudo de apreensão da 'res furtiva' que não afasta a materialidade de crime contra o patrimônio, sobretudo em se tratando de 'tentativa' - Mérito - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - réu que negou a prática delitiva - negativa que não prospera - vítima que, em juízo, confirmou que a entrada do réu se deu por meio de arrombamento da porta e escalada do muro, afirmando que o muro mede cerca 1,80 metros. Teve conhecimento de que o réu já tinha separados objetos de pequeno valor - Policiais Militares relataram que o COPOM os informou sobre um possível furto no local dos fatos. Lá chegando, visualizaram o réu deixando o imóvel e o abordaram, e perceberam que a porta da cozinha estava arrombada, e que havia uma sacola com utensílios de alumínio já separados - Palavras da vítima e dos policiais que merecem credibilidade - Crime tentado - Furto dito 'privilegiado' - impossibilidade - falta de amparo legal - Qualificadoras consistentes no rompimento de obstáculo e escalada caracterizadas - De rigor a condenação - Dosimetria - Penas e regime prisional mantidos - erro material corrigido de ofício, para redimensionar a pena pecuniária - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - requisitos não preenchidos - Preliminar rejeitada - Recurso improvido. (TJ-SP, Apelação 0001955-44.2016.8.26.0604, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 22/06/2017, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:

23/06/2017)

Logo, possível concluir que, no caso em questão, houve a utilização de esforço anormal, restando configurada a qualificadora de escalada.

Importante mencionar que, ainda que somente o acusado Andrei tenha pulado o muro, trata-se de circunstância objetiva, de modo que se comunica ao côrreu Amaury, nos termos do artigo 30 do Código Penal.

Destarte, cumpre frisar que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em sede de recurso repetitivo (TEMA 1087 - REsp 1.888.756/SP, RESP 1.890.981/SP e RESP 1.891.007/RJ), entendeu pela impossibilidade de a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) incidir no crime de furto qualificado (§ 4º).

Assim, alterando posicionamento anterior e curvando-me ao entendimento explicitado pelo Superior Tribunal de Justiça, afasto a incidência da causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do CP (repouso noturno). Contudo, anoto que tal circunstância pode ser observada na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo nos casos de furtos cometidos em estabelecimento comercial, tendo em vista que a vigilância da vítima se torna menos eficiente e o patrimônio, portanto, mais vulnerável.

Assim, conforme o exposto há nos autos, elementos seguros que vêm confirmar a materialidade e autoria dos delitos que recaem sobre os acusados. A prova carreada aos autos é forte e coesa e, por se enquadrar, a conduta dos acusados, no conceito de fato típico e antijurídico, e não havendo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

a) Com relação ao acusado Andrei Luciano Roque:

Ressalto que, em razão de economia processual, e tratando-se de delitos patrimoniais da mesma espécie, procederei à dosimetria da pena em relação aos dois crimes de furto qualificado em uma só oportunidade.

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do acusado, deve ser considerada normal. O acusado possui maus antecedentes criminais, ostentando inúmeros envolvimentos na prática de crimes patrimoniais (Fls. 121/122 - 000923-82.2010.8.26.0646; e fls. 122/123 - 000958-82.2010.8.26.0646), dando claras demonstrações de ser ele um infrator contumaz, justificando um maior rigor na aplicação da reprimenda penal. Sobre a conduta social do acusado e sua personalidade, não foram amealhados elementos suficientes a ensejarem maior repreensão, nos termos em que decidiu o STJ (HC 472.654 - DF, 6ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 21/02/2019 - Informativo 643). Os motivos são próprios do tipo penal, pela expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia.

As circunstâncias devem ser valoradas negativamente. Com efeito, "reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou com circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante" (HC 308.331/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017). Assim, utilizei-me da qualificadora do concurso de agentes para qualificar o crime, ao passo que a qualificadora da escalada será utilizada como circunstância judicial desfavorável.

Ainda, reconheço como circunstância judicial negativa o fato de o furto ter sido praticado durante o repouso noturno, tendo em vista que a vigilância da vítima se torna menos eficiente e o patrimônio, portanto, mais vulnerável.

As consequências foram normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Diante destas circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base acima do mínimo legal, resultando em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), mas também presente a reincidência múltipla (Fls. 119 - 0000613-95.2018.8.26.0646; Fls. 119/120 - 0000724-60.2010.8.26.0646; Fls. 120/121 - 0000728-97.2010.8.26.0646; Fls. 123 - 0001036-36.2010.8.26.0646; Fls. 125 - 00001895-52.2010.8.26.0646).

Como o réu é multirreincidente, incabível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a reincidência. De fato, segundo o e. STJ, "tratando-se de réu multirreincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência, implicaria em ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. A multirreincidência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força, apenas, de um único evento isolado em sua vida, devendo, pois, prevalecer sobre a confissão." (AgRg no REsp 1424247/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 13/02/2015). Assim, aumento a pena em 1/3 (um terço) fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, é inaplicável o privilégio previsto no artigo 155, §2º, do Código Penal, em razão da reincidência do acusado. Também não se aplica a causa de aumento prevista no parágrafo primeiro do artigo 155 (praticado durante o repouso noturno), conforme fundamentação desta sentença. Assim, fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

DO CRIME CONTINUADO:

Verifica-se que os dois crimes de furto imputados ao acusado foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Assim, de rigor reconhecer o crime continuado, à luz do disposto no artigo 71, caput, do Código Penal. Nesse passo, em vista da identidade de pena se da quantidade de crimes praticados, aumento uma das reprimendas em 1/6 (um sexto), razão pela qual torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

As penas de multa, nos termos do artigo 72 do Código Penal, devem ser aplicadas distintas e integralmente, somando, assim, 40 (quarenta) dias-multa.

b) Com relação ao acusado Amaury Ventura Barreto:

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do acusado, deve ser considerada normal. O acusado possui maus antecedentes (fls. 127/128), ostentando condenação apta a configurar reincidência. Todavia, a fim de evitar bis in idem, deixarei para valorá-la na fase seguinte. Sobre a conduta social do acusado e sua personalidade, não foram amealhados elementos suficientes a ensejarem maior repreensão, nos termos em que decidiu o STJ (HC 472.654 - DF, 6ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 21/02/2019 - Informativo 643). Os motivos são próprios do tipo penal, pela expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia.

As circunstâncias devem ser valoradas negativamente. Com efeito, "reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para

tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou com circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante" (HC 308.331/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017). Assim, utilizei-me da qualificadora do concurso de agentes para qualificar o crime, ao passo que a qualificadora da escalada será utilizada como circunstância judicial desfavorável.

Ainda, reconheço como circunstância judicial negativa o fato de o furto ter sido praticado durante o repouso noturno, tendo em vista que a vigilância da vítima se torna menos eficiente e o patrimônio, portanto, mais vulnerável.

As consequências foram normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Diante destas circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base acima do mínimo legal, resultando em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, ausentes circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (fls. 127 - processo 0014743-17.2007.8.26.0019). Assim, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, é inaplicável o privilégio previsto no artigo 155, §2º, do Código Penal, em razão da reincidência do acusado. Também não se aplica a causa de aumento prevista no parágrafo primeiro do artigo 155 (praticado durante o repouso noturno), conforme fundamentação desta sentença. Assim, fixo a pena definitiva em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

DO CRIME CONTINUADO:

Verifica-se que os dois crimes de furto imputados ao acusado foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Assim, de rigor reconhecer o crime continuado, à luz do disposto no artigo 71, caput, do Código Penal. Nesse passo, em vista da identidade de pena se da quantidade de crimes praticados, aumento uma das reprimendas em 1/6 (um sexto), razão pela qual torno a pena definitiva em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão.

As penas de multa, nos termos do artigo 72 do Código Penal, devem ser aplicadas distintas e integralmente, somando, assim, 30 (trinta) dias-multa.

O valor do dia-multa será de 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo à época dos fatos, pois não há, nos autos, informações sobre a real situação econômica dos acusados que autorize a fixá-lo acima desse patamar.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal de ambos os acusados deverá ser o fechado, diante da reincidência, do quantum de pena imposta e das circunstâncias judiciais desfavoráveis (furto duplamente qualificado, praticado por meio de concurso de agentes e escalada, durante o repouso noturno), nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'b', e § 3º, do Código Penal.

Tendo em vista tratar-se de acusados reincidentes e o montante de pena aplicada, incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal, não sendo a medida socialmente recomendável.

Impossível, também, em face do artigo 77, inciso I, do Código Penal, a suspensão da

execução da pena.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência:

I) CONDENO o acusado ANDREI LUCIANO ROQUE, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, no valor cada dia de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º, do Código Penal. Isto por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 155, parágrafo 4º, incisos II e IV, do Código Penal, por 02 (duas) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (crime continuado).

II) CONDENO o acusado AMAURY VENTURA BARRETO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor cada dia de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º, do Código Penal. Isto por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 155, parágrafo 4º, incisos II e IV, do Código Penal, por 02 (duas) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (crime continuado).

Por não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, os acusados poderão recorrer em liberdade, conforme artigo 387, parágrafo único, do mesmo diploma legal, salvo se por outro motivo estiverem presos.

Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar indenização mínima, ante a ausência de pedido na denúncia e de detalhamento durante a instrução processual.

Por fim, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os acusados ao pagamento de 100 (cem) UFESP's a título de taxa judiciária, observada a concessão da gratuidade da justiça (fls. 255).

Intimem-se as vítimas sobre o teor desta sentença, nos termos do artigo 201, §2º, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências:

- 1) Expeça-se mandado de prisão e guia definitiva para o cumprimento da pena;
- 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- 3) Comunique-se o IIRGD e proceda-se ao lançamento das informações pertinentes no Sistema Informatizado Oficial; e
- 4) Nos termos do Provimento CG 05/2022 (disponibilizado no DJE em 13/05/2022, p. 31), não havendo recolhimento de fiança no presente caso, consigno que o acusado deverá ser citado para pagamento da multa penal apenas no Juízo da Execução Penal, ficando dispensada a intimação pelo Juízo de Conhecimento.

P.I.C.

Urania, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA